

1501088-08.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... porque o local era ponto de tráfico. Fazia "bicos" de pizzaiolo. Tem 21 anos e possui condenação posterior por tráfico.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que o local (Passagem Águas Claras) é conhecido ponto de tráfico, avistaram o réu e outro homem na via pública, e resolveram abordá-los. Relataram que localizaram no bolso de Leonardo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1501088-08.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501088-08.2021.8.26.0537

2021/000734

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

KELVEN COSTA ROCHA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

KELVEN COSTA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 61, inc. II, alínea "j", porque no dia 30 de maio de 2021, por volta das 22:30 horas, na Rua José Vicente, altura do n.º 114, Passagem Águas Claras, Bairro Jardim Inamar, adquiriu, recebeu e trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi concedida liberdade provisória ao réu, por decisão da Juíza de plantão, em 31.05.21 (fls. 38/42).

Apresentada a defesa prévia (fls. 87/88), foi recebida a denúncia em 27.05.22 (fls. 90/91). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, afastada a redução do art. 33, §4.º e a substituição por pena restritiva de direitos por ter respondido por ato infracional e possuir condenação posterior por tráfico, a fixação de regime fechado e a perda do dinheiro apreendido.

O Dr. Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação que sejam consideradas a menoridade, confissão, primariedade, que seja afastada a agravante da pandemia, a aplicação da redução do art. 33, §4.º, regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o acusado confessou a prática do crime (fls. 04). Disse que foi até o local do fato, onde funciona uma "boca de fumo", por volta das 20:00 horas, encontrou um homem que estava traficando e recebeu alguns entorpecentes para vender até as 08:00 do dia seguinte (31.05.21). Falou que receberia R\$ 0,50 por cada porção de droga vendida. Declarou que quando foi surpreendido e detido pelos policiais estava com uma bolsa pequena, de cor amarela, onde guardava as drogas e o dinheiro do tráfico. Afirmou que vendeu uma porção de maconha para Leonardo, antes da chegada dos policiais. Narrou que era a primeira vez que vendia drogas e que havia começado a traficar para ajudar financeiramente a família.

Em juízo, afirmou que foi comprar drogas, ele e Leonardo se evadiram e foram abordados. Os policiais acharam as drogas na viela. Negou estar com drogas. Não conhecia os policiais. Nunca foi processado. Foi incriminado, porque o local era ponto de tráfico. Fazia "bicos" de pizzaiolo. Tem 21 anos e possui condenação posterior por tráfico.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que o local (Passagem Águas Claras) é conhecido ponto de tráfico, avistaram o réu e outro homem na via pública, e resolveram abordá-los. Relataram que localizaram no bolso de Leonardo uma porção de maconha. Afirmaram que encontraram com o réu, dentro uma pequena bolsa de cor amarela que ele segurava, 29 porções de maconha, 52 invólucros de cocaína, 49 pedras de "crack" e a quantia de R\$ 262,50. Informaram que o réu confessou. Falaram que Leonardo alegou ser usuário e que não tinha nenhum envolvimento com o tráfico.

Diego (policial), em juízo, narrou que nas proximidades da viela Águas Claras, onde há tráfico, avistaram o réu e um usuário. O réu segurava uma bolsa pequena amarela, onde havia drogas e dinheiro. Informou que o réu confessou o tráfico, alegando que estava desempregado e era a forma para obter renda. Não conhecia o réu anteriormente. Em poder do usuário havia uma maconha.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Heitor. O réu confessou o tráfico e informou que o outro rapaz era usuário. Não conhecia o réu. Na época o réu estava com cabelo amarelo.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 10 - 30 porções de maconha, 52 invólucros de cocaína e 49 pedras de "crack") e diversidade (maconha, cocaína e "crack"), o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro (fls. 10), a confissão informal e extrajudicial, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Portanto, não é caso de absolvição.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (30 porções de maconha, 52 invólucros de cocaína e 49 pedras de "crack"), demonstram que se destinava ao tráfico.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 12/15) e laudo definitivo (fls. 72/73 e 74/76).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (F.A de fls. 107/109), ostentando condenação posterior que não pode ser considerada como antecedentes (fls. 119/120).

"Na colocação da pena-base não pode o Magistrado considerar, para situá-la acima do mínimo legal, circunstâncias posteriores ao fato em causa ou com ele contemporâneas, tais como, por exemplo, outras condenações impostas ao acusado em diferentes processos que tenham tido o desate após o crime ventilado no feito (JUTACRIM 45/221). No mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM 29/356, 30/414" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 334). Inobstante o réu tenha respondido por atos infracionais, os fatos praticados antes dos 18 anos não podem ser considerados em seu desfavor, já que conforme F.A de fls. 107/109 é primário e não ostenta antecedentes criminais (STJ, 5^a Turma, HC 289.098/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/05/2014, HC 249015/SP, HC 81866/DF).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado.

Compenso a agravante de ter sido cometido o crime em ocasião de estado de calamidade (pandemia Coronavírus/Covid-19) com a menoridade do acusado e confissão extrajudicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito a decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EResp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (30 porções de maconha, 52 invólucros de cocaína e 49 pedras de "crack") já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que na época dos fatos se dedicava a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, §4.º). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e §3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, menor de 21 anos, não ostenta antecedentes criminais, confessou na fase policial, demonstrando arrependimento, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO KELVEN COSTA ROCHA à pena de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 10 e 70) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à bolsa tipo "nécessaire", sem marca aparente, apreendida (fls. 10), já periciada (fls. 79/80), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 43), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 13 de junho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA